

1501097-63.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... indícios acerca da prática do crime de tráfico, o mesmo não se pode dizer sobre a existência de prova robusta e cabal para embasar um decreto condenatório por tráfico de drogas, exigência inafastável no presente caso, pois as provas produzidas nos autos não são contundentes nesse sentido, devendo prevalecer a cautela e a ponderação a fim de se evitar a condenação de alguém ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

1501097-63.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501097-63.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

DAVI VINÍCIUS DE FREITAS EVANGELISTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na denúncia, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 18h40, na rua Wandenkolk, n.º 3236, bairro Rosele, nesta cidade, o réu trazia consigo e transportava droga para consumo de terceiros, consistente em 21,67 gramas de "cocaína", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 31/07/2021 (fls. 03/04). Pela r. decisão de fls. 61/64 foi concedida ao acusado a liberdade provisória, com cumprimento do alvará de soltura em 01/08/2021 (fls. 76/77).

Devidamente notificado (fl. 139), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 143/147. A denúncia foi recebida em 07 de abril de 2022 (fls. 158/161). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo, ao final, interrogado o réu (fls. 195/202).

Em alegações finais orais (fl. 195/196), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito disposto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Na dosimetria da pena, requereu sejam observados os maus antecedentes e a reincidência, manifestando-se pela aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade.

Em alegações finais orais (fls. 195/196), a Defesa pugnou, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade quanto ao procedimento de abordagem efetuado. No mérito, requereu a desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, conforme artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

#### FUNDAMENTO.

De início, não há que se cogitar eventual nulidade, vez que a a abordagem e busca pessoal se iniciaram por conta da atitude suspeita do acusado, certo que, como relatado pelos policiais militares, ao se deparar com a viatura, foi visto dispensando algo ao chão, além de ter realizado manobra suspeita com a motocicleta que pilotava, dando, assim, ensejo ao procedimento.

No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 37), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 87/89), relatório policial (fls. 121/122), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a autoria no tocante ao crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, não ficou devidamente comprovada nos autos.

A testemunha comum Jose Antonio Duarte Pinto, policial militar ouvido em juízo (fl. 199), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 08), disse que estavam em patrulhando pela rua Wandenkolk, quando avistaram um motociclista adentrando o bairro Rosele. Quando o indivíduo avistou a equipe, colocou a mão no bolso e arremessou algo ao solo. Para se evadir, tentou fazer uma manobra com a motocicleta, porém não conseguiu e foi abordado. Na revista pessoal foi encontrado em seu bolso 03 (três) pinos de cocaína, uma nota de R\$ 2,00 (dois reais) e um aparelho celular Samsung. No lugar em que o acusado havia arremessado algum objeto foram localizados mais 12 (doze) pinos, idênticos aos que estavam em sua posse. Não se recorda do horário exato do ocorrido, mas estava perto do entardecer com uma boa visibilidade devido às luzes artificiais. Estavam aproximadamente a 15 metros do indivíduo quando o avistaram arremessando o objeto pelo lado direito, próximo da calçada. Quando houve o arremesso, os objetos se espalharam pelo solo, e então os policiais tiveram que peregrinar para arrecadá-los. Não se recorda da cor exata, apenas que os tubos eram idênticos aos encontrados com o réu. A via não é conhecida como ponto de tráfico, mas sim o interior do bairro. Não conhecia Davi, mas os outros policiais, sim. Quem localizou os três pinos no bolso do acusado foi o outro policial (Santos). Não prestou atenção na abordagem pois estava fazendo a segurança da equipe. Abordaram o réu em razão do arremesso dos objetos e diante da manobra que ele fez com o veículo. Neste bairro sempre têm denúncias sobre tráfico, inclusive recaindo sobre o irmão do acusado, mas quanto a ele, não. Não houve

indicativo de que o réu estaria traficando; ele apenas tentou fugir antes da abordagem. Não foram até sua residência. A cor dos pinos não se recorda, acredita serem brancos e que armazenavam cocaína. Não se recorda do exato fluxo de pessoas na rua naquele dia.

A testemunha comum José Roberto dos Santos, policial militar ouvido em juízo (fl. 198), em consonância com o depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 10), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Rosele, quando se depararam com um indivíduo de motocicleta. Quando notou a presença da viatura, o réu colocou a mão em seu bolso, retirou algo e jogou ao solo. Tentou se evadir da abordagem, sem êxito. Em busca pessoal foram encontrados 03 (três) microtubos de cocaína, R\$ 72,00 (setenta e dois reais) e um aparelho celular com a tela quebrada. Ao voltarem para o lugar em que o acusado havia lançado o objeto, foram encontrados mais 12 (doze) microtubos, idênticos aos que foram encontrados no bolso do acusado, também com cocaína. Não conhecia o réu, mas seus colegas de trabalho o reconheceram de outras diligências. Estavam a aproximadamente 20 metros do indivíduo quando o avistaram arremessando o objeto. Não se recorda do horário exato do ocorrido, mas estava perto do entardecer com uma boa visibilidade. O bairro é conhecido como ponto de tráfico, onde geralmente são feitas entregas por meio de motos, bicicletas ou a pé. O réu lançou os objetos com a mão esquerda para o sentido contrário. Nunca efetuou a prisão de alguém que tenha afirmado ter adquirido entorpecentes do acusado. Não foi até a residência do indivíduo. Nunca haviam investigado o acusado, nem havia algum mandado contra ele. Depois de abordado, o réu colaborou com a investigação. Não se recorda se o réu os informou sobre o destino que daria às drogas em sua posse, mas ele disse que era usuário de entorpecentes.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 197), o réu DAVI VINICIUS DE FREITAS EVANGELISTA disse que estava passando pela rua Marechal Mascarenhas de Moraes na posse de 3 (três) pinos de cocaína em seu bolso direito. Admite ser usuário de cocaína. Os policiais jogaram a viatura contra ele e em nenhum momento tentou fugir. Falou para os policiais que se tratava de um usuário e que possuía esses 3 pinos, e que inclusive já tinha usado alguns naquele dia e estava indo para a residência de sua mãe. Nega que tenha arremessado alguns objetos antes da abordagem e nem viu os policiais procurando por eles. Na mesma hora em que foi abordado já informou aos policiais sobre a posse referente aos três pinos, momento em que recebeu socos dos policiais. Usa por dia cerca de 5 a 10 pinos, e paga dez reais por cada um. Trabalha como ajudante de pedreiro e ganha R\$ 80,00 por dia. Já teve passagem por tráfico. A mão em que acelera a moto é a direita. A todo momento ficou tranquilo com a situação. Adquiriu esses três pinos, mas já havia utilizado dois antes. Não usou os outros três, pois estava indo para casa. Comprou as drogas naquele mesmo dia em uma praça. Alega que o policial Santos o agrediu, desferindo socos em seu peito. Não conhecia o policial. Se não retirasse a perna a viatura teria passado por cima. Caiu da motocicleta pois foi atropelado pela viatura; não relatou isso na delegacia, pois os agentes o instruíram para que não o fizesse. Atualmente trabalha com seu padrao Paulo.

Encerrada a instrução processual, entendo que o conjunto probatório formado nos autos apresenta-se frágil quanto ao envolvimento do acusado no crime de tráfico de drogas.

As testemunhas policiais militares ouvidas em juízo se recordam de terem avistado o acusado arremessando objetos em direção ao solo quando avistou a viatura. Afirmaram, contudo, não o conhecerem nos meios policiais. Ainda, o réu lhes relatou que os 03 (três) pinos de cocaína encontrados em seu bolso eram destinados a seu próprio uso, vez que usuário de cocaína.

Quanto ao acusado, este negou a prática do delito tanto em seu interrogatório na fase inquisitiva (fl. 12), quanto em juízo, afirmando ser apenas usuário de cocaína. Relatou, ainda, que os 12 (doze) pinos da droga encontrados no chão pelos

agentes não eram de sua propriedade.

Em que pese a versão apresentada pelos policiais militares, entendo que há dúvida razoável quanto à destinação do entorpecente à mercancia ilícita.

Observa-se que os agentes não presenciaram nenhum ato suspeito ou de mercancia por parte do réu que demonstrasse a comercialização de entorpecentes. O acusado, ao ser abordado, explicou que os pinos localizados em seu bolso destinavam-se ao seu próprio consumo, bem como que o dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho.

Assim, dentre as provas desfavoráveis ao réu, há somente o testemunho dos policiais que efetuaram sua abordagem e prisão, bem como a apreensão do entorpecente, que não se trata de quantia exorbitante para uso.

Também não foi apreendido nenhum apetrecho na posse do réu que pudesse indicar a prática do delito.

Em que pese o depoimento dos policiais no sentido de que encontraram pinos de cocaína cheios no lugar em que viram o réu dispensando algo, a destinação da droga não ficaram devidamente demonstradas, sobretudo ante a inexistência de outras circunstâncias que, somadas, pudessem concluir pela certeza da prática do delito.

Dado o sistema de valoração de provas do nosso Direito Penal, em que a dúvida favorece ao réu, a nebulosidade do caso concreto não deixa transparecer um caminho seguro para a condenação.

Assim, se é correto afirmar que há indícios acerca da prática do crime de tráfico, o mesmo não se pode dizer sobre a existência de prova robusta e cabal para embasar um decreto condenatório por tráfico de drogas, exigência inafastável no presente caso, pois as provas produzidas nos autos não são contundentes nesse sentido, devendo prevalecer a cautela e a ponderação a fim de se evitar a condenação de alguém que possa ser inocente.

Este também é o entendimento do ilustre representante do Ministério Público que, em sede de alegações finais, pugnou pela desclassificação do tipo penal para aquele previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a dúvida quanto à destinação da droga.

É notória a gravidade das consequências decorrentes de uma condenação criminal, ainda mais pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, entendo necessária a existência de conjunto probatório mais completo e significativo a condenação.

Portanto, não é possível afirmar, com certeza, que o réu estava traficando, devendo prevalecer a não incidência do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido: "TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

Frise-se que não se está afirmando aqui que as porções eram, sem dúvida, para o seu consumo, pois os meios de prova disponíveis não permitem uma afirmação conclusiva em favor do acusado. No entanto, também não permitem afirmar o contrário, ou seja, que as drogas se destinavam ao tráfico.

Portanto, diante da quantidade de droga apreendida, das circunstâncias e das provas produzidas, impõe-se a desclassificação do delito descrito na denúncia para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Observo que o réu é reincidente na prática delituosa, por conta da condenação transitada em julgado cuja certidão foi acostada às fls. 44/45 (autos nº 0021959-09.2015.8.26.0032). Contudo, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por ter confessado o delito em questão.

Não há outros elementos desfavoráveis ao acusado, razão pela qual entendo por suficiente e razoável a aplicação da pena de advertência sobre o efeito das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu DAVI VINÍCIUS DE FREITAS EVANGELISTA na denúncia, CONDENANDO-O, pela prática do crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da referida lei, designando-se audiência, oportunamente.

Em face da natureza da pena imposta, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Por fim, DETERMINO a restituição da quantia de R\$ 72,00 (fl. 86) e a devolução do aparelho celular apreendido (fl. 34) em favor do acusado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas na forma da lei (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Publique-se e intime-se.

Araçatuba, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA